

1500101-83.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ana Leticia Oliveira Dos Santos

Comarca: São Luiz do Paraitinga

Foro: Foro de São Luiz do Paraitinga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... conhecimento do envolvimento dele com o tráfico, tanto que ele fora preso há um tempo atrás. Já conhecia os acusados, porque já haviam sido alvo de denúncias de tráfico envolvendo ambos. As denúncias sempre mencionavam as mesmas características do veículo. Fora encontradas 63 pedras de crack.

A testemunha Rogério Dias, policial militar, narrou que, na data dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Luiz do Paraitinga

Foro de São Luiz do Paraitinga

Vara Única

Avenida Vereador José Adolfo Pinto De Souza, s/nº, São Luiz do Paraitinga - SP - cep 12140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500101-83.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500101-83.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN FRANCISCO LEMES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Leticia Oliveira Dos Santos

Vistos.

JEAN FRANCISCO LEMES, qualificado à fl. 04, e ALESSANDRA APARECIDA DE TOLEDO, qualificada à fl. 05, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 12h10min, na Rua Ver. José Pinto de Souza, nº 687, centro, na via pública, nessa Cidade e Comarca, os acusados, unidos subjetivamente e com unidade de desígnios, traziam consigo, drogas, consistentes em 63 (sessenta e três) pedras de crack, perfazendo um total de 02 (dois) gramas, conforme laudo químico toxicológico definitivo de fls. 76/78.

Pedido de restituição de veículo formulado por Cleusa Lanziloti Lemes às fls. 89/93, com documentos (fls. 94/100).

Notificados (fls. 127 e 130), os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 131/136), com documentos (fls. 139/140).

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (fls. 155/160).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma testemunha de defesa, sendo, ao final, os réus interrogados. Em debates, a Acusação postulou a procedência do pedido (fls. 270/271).

Em memoriais, a Defesa pugnou pela absolvição dos acusados, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, rogou pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso de condenação pela imputação original, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, reiterou pedido de restituição de veículo à terceira interessada (fls. 274/294).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação provisória de fls. 11/13, exame toxicológico definitivo (fls. 263/265) e laudo de fls. 266/269, bem como pela prova oral produzida.

Em seu interrogatório, a ré Alessandra Aparecida de Toledo informou que tem 35 anos, vive em união estável com Jean, tem uma filha de 5 anos com ele e um filho de 13 anos fruto de outro relacionamento, que não mora consigo. Concluiu o ensino médio. Disse que trabalhava fazendo unhas, faxina, leite, frango caipira. Sua renda era mais ou menos de 700 reais. A renda dele era de aproximadamente 1000 reais. Está, no momento, internada para tratamento de dependência química. Faz uso de cocaína e crack. É a primeira vez que é internada. Vai fazer dois meses que está internada. Jean nunca foi internado. Sobre os fatos, declarou que, naquele dia, queriam fazer uso da substância e saíram para comprar. Resolveram comprar uma quantidade que fosse suficiente para 10 dias. Pagava 120 reais por 2 gramas. Comprava por grama. E, como não tinham por grama, naquele dia, deram para eles no "sacolé". Eram umas 60 pedras. Prefere manter em sigilo a identidade de quem vendeu. Compararam na Várzea dos Passarinhos. Indagada se costumavam comprar droga lá, disse que "nem todas as vezes". Usava todos os dias. Alega que nunca fez uso perto de sua filha, que ficava com a sua sogra nessas ocasiões. Aduziu que faz 10 anos que tem o vício, mas que nunca se gravou tanto a ponto de querer se internar. Está casada com Jean há 10 anos. Asseverou que iniciaram o uso das drogas juntos. Ao final, confirmou que as drogas eram deles, mas se destinavam ao seu uso pessoal. O carro em que trafegavam era de sua sogra; disse que pegavam escondido. Disse que está melhor e já engordou 5 quilos.

Interrogado, o réu Jean Francisco Lemes declarou que tem 40 anos, vive em união estável com Alessandra há 10 anos, tem uma filha com ela, além de dois filhos de outro relacionamento. Trabalha no sítio do seu pai, arrumando cerca, roçando pasto, tirando leite. Seu pai tem gado, mas não informou quantos. Sua renda advém desse trabalho, alegando que sua mãe o ajuda. Acha que ganha em torno de mil reais por mês. Nunca foi preso nem processado antes. Estudou até a 7ª série. Tem problema com álcool e drogas, principalmente, crack. Acha que faz uns 15 anos ou mais que é usuário. Nunca foi internado para tratamento de dependência química. Sobre os fatos, narrou que pegou a droga "na Várzea" e, quando estava dando a volta próximo ao Fórum, foi abordado pelos policiais. Foi pegar dois gramas de drogas, pagando 120 reais. Era para seu uso. Alessandra também usa. Nem sempre compravam a droga lá. Alessandra matava frango para vender, além de vender "uns queijinhos" e fazer umas faxinas. Acha que ela conseguia tirar em torno de 500 reais por esses serviços. A droga estava realmente com ela, como os policiais narraram. Moram a uns 4 km do local dos fatos. Usa droga umas duas vezes e afirma que sua filha fica com sua mãe nessas ocasiões. Sua mãe, agora, está sabendo que o depoente faz uso de drogas. Disse que a criança morava consigo e com sua esposa, mas quando queriam usar drogas, deixavam-na com sua mãe. Sua menina ficava bastante com sua mãe. Alessandra usava menos que o depoente. Aduziu que as drogas apreendidas seriam usadas em, mais ou menos, 10 a 15 dias. Guardava as drogas perto da caixa d'água. Até tinha medo de ser abordado com as drogas, mas acreditava que não iria acontecer consigo. Conseguia controlar o vício para usar essa droga fracionada no período

desejado. Já foi abordado, anteriormente, pelos policiais, porque sabiam que não tinha habilitação. Tem habilitação, mas, como está usando drogas, não tem como renová-la. Sua carta é de carreta e precisa fazer o toxicológico. Não era sempre que estava com essa quantidade de drogas. O carro usado para comprar as drogas era de sua mãe, pegava escondido, sem que ela soubesse. A caixa d'água onde escondia as drogas ficava longe de sua casa, situada próximo ao pasto. Nunca usou drogas perto de sua filha, nunca usou dentro de sua casa.

A testemunha Ricardo Leal Fontela, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, receberam denúncia de que um veículo Palio Weekend na cor prata, com um casal a bordo, estaria pela Avenida Várzea dos passarinhos a fim de buscar entorpecentes na casa de Daniel. Munidos das informações, fizeram patrulhamento e lograram êxito em encontrar com o mencionado veículo. Fizeram a busca no veículo e pessoal no Jean, porém, nada de ilícito foi encontrado. A ré demonstrou nervosismo, até chorou durante a abordagem, razão pela qual a indagaram se ela portava alguma coisa, tendo ela dito que sim, que estava com entorpecentes. Informaram-na, então, que fariam solicitação da presença de uma policial feminina para fazer revista, oportunidade em que ela colocou a mão no interior da blusa e retirou um pacote contendo pedras de crack. Aparentemente, a ré tirou o pacote do interior do sutiã. Ela entregou espontaneamente. As drogas estavam em fitas que geralmente têm 13 pedras. Não se recorda se comentaram se era para uso ou para venda. A denúncia mencionava apenas o veículo e o fato de estar um casal em seu interior. O veículo foi abordado próximo ao Fórum, em frente ao restaurante Estrela. Não fizeram diligências relacionadas a Daniel. Mas tinham conhecimento do envolvimento dele com o tráfico, tanto que ele fora preso há um tempo atrás. Já conhecia os acusados, porque já haviam sido alvo de denúncias de tráfico envolvendo ambos. As denúncias sempre mencionavam as mesmas características do veículo. Fora encontradas 63 pedras de crack.

A testemunha Rogério Dias, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estavam na base da PM, quando receberam ligações anônima informando que um casal, em um veículo Palio Weekend, estava indo à casa de uma pessoa chamada Daniel para buscar entorpecentes. Foram até o local e, no caminho, depararam-se com o veículo, fizeram a busca pessoal no Jean e vistoria no veículo, porém, nada de ilícito foi encontrado. Perceberam que a ré estava muito nervosa, de maneira que indagaram se ela estava com drogas, ela se mostrou receosa, e informaram a ela que chamaram apoio de uma policial feminina. Nesse momento, ela admitiu que estava com a droga, que estava no interior de seu sutiã. Solicitaram que ela apresentasse, tendo ela retirado e entregue os entorpecentes. Não se recorda se, no momento da abordagem, mencionaram a que as drogas se destinavam. Sabe que os réus têm um relacionamento, mas não sabe se são casados ou se são namorados. Já conhecia o casal por denúncias anteriores de tráfico de drogas no município. Mas, não se recorda de tê-los abordados anteriormente. Daniel, mencionado na denúncia, era conhecido dos meios policiais por desenvolver o tráfico na casa dele, tanto é que, pouco depois dessa prisão, Daniel foi preso. A denúncia anônima mencionava que era um casal e o veículo, mas não informou nomes. O denunciante não se identificou. O carro foi localizado próximo à casa de Daniel. Afirmou que as drogas estavam em porções prontas para venda. Eram 63 pedras de crack dentro de um saco plástico. A denúncia mencionava que o casal estava indo buscar a droga na casa do Daniel. Pelo que saiba, anteriormente a esta abordagem, não foram localizadas drogas com eles. Daniel é conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas. Ele guardava a droga na casa dele e distribuía para os demais que vendiam na cidade.

A testemunha de Defesa, Carlos Rodolfo Antunes dos Santos, afirmou que conhece os réus, sendo que Alessandra era sua vizinha. Os réus são casados, têm filhas, e residem na casa da mãe de Jean. Conhece a ré desde a infância, e Jean, há, aproximadamente, 15 anos. Não tem conhecimento de fatos desabonadores envolvendo os réus. Disse que Jean trabalha, ajudando o pai dele "na roça". Alessandra não trabalha fora. Declarou que os réus fazem uso de drogas. Nunca os viu usando, mas, pelo que percebe, eles fazem uso. Jean já disse que usa drogas. Alega que Jean "está mudado" e acredita que esteja se tratando. Acha que eles "devem" usar crack, pelo jeito que eles ficavam. Indagado se, ainda assim, a filha do casal morava com eles, respondeu que eles saíam pra fazer uso de drogas sem a criança. Afirmou que a

criança ficava com a mãe de Jean.

Os depoimentos das testemunhas comuns foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar os réus.

O testemunho dos policiais é válido para a prolação do édito condenatório. Com efeito, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Muito pelo contrário, as palavras de policiais, acerca de fatos que no exercício de seu mister tenham presenciado, revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos em geral.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo a valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos. Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF, 1.^a Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

Nesse contexto, em que pese o empenho da combativa defesa, não há como se afastar o reconhecimento da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelos réus, sobretudo diante do teor dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados, pois confirmaram os termos da inicial acusatória e evidenciaram a sua responsabilidade criminal no que tange ao crime de tráfico ilícito, não se cogitando de contradição de relevo nem de viés sorrateiro, a revelar que merecem credibilidade e não podem ser simplesmente ignorados, mesmo porque foram seguros e coerentes, desde o início, e, ademais, como salientado, não tinham motivos para atribuir-lhes, falsamente, crime de tal gravidade, nada existindo de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou estreme de dúvida, em razão da razoável quantidade da droga apreendida em cotejo ao curto espaço de tempo para seu consumo, forma de acondicionamento (prontas para venda a varejo), e das denúncias de que os réus estariam buscando drogas com Daniel, a que incumbiria a distribuição de drogas na localidade para sua revenda nos pontos de tráfico da cidade.

De mais a mais, insta destacar que a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Nesse sentido, destaque:

Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para consumação de delito (TJSP - HC 39.141-3 - Rel. Denner de Sá - RJTJSP 97/512). (Grifei).

Tóxico - Art. 12 c/c artigo 18, III da Lei 6.368/76 - Maconha e cocaína encontradas no carro de propriedade da acusada e no qual a mesma se encontrava distribuindo o produto por diversos pontos suspeitos - "Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, na modalidade de traficância, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa (TJDF - AC 9.073 - Rel. Hermenegildo Gonçalves - DJU 16.9.88, P. 23.456). No mesmo sentido: RT 675/406. (Grifei).

O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua

consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância (TJSP - AC 6.635 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 70/371). No mesmo sentido RJTJSP 63/316; JC 68/415 e 63/262. (Grifei).

Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para a comercialização (RT 714/357, Rel. Des. Jarbas Mazzoni). (Grifei).

Não se ignora que a corré Alessandra esteja internada em clínica de reabilitação, no entanto, é, no mínimo, curioso, que a internação tenha ocorrido após ter sido flagrada pelos policiais, sendo que, segundo a própria, possui o vício em drogas há quase 10 anos. Consigno, ademais, que a renda do casal não restou suficientemente esclarecida, sendo incompatível com as atividades alegadamente exercidas. Nesse sentido, não custa rememorar que a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08).

Enfim, demonstrada a materialidade e autoria do fato típico, não sendo possível a desclassificação do crime, uma vez comprovada a intenção da traficância, de rigor a condenação dos réus pelo cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Sendo de rigor a condenação, passo a dosar a pena.

Da ré Alessandra Aparecida De Toledo

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código penal, verifica-se que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta da acusada, não deve lhe prejudicar, porquanto comum para esse tipo de crime; os antecedentes não lhe prejudicam, porquanto é primária (fls. 261/262); inexistem elementos suficientes para se definir a personalidade da agente e conduta social; os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias também não devem aumentar a pena-base, já que não apresentam peculiaridades que justifiquem a sua exasperação; as consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime.

Por outro lado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não há, nas circunstâncias judiciais preponderantes, nenhuma peculiaridade a justificar a exasperação da reprimenda.

Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes e, fixada a pena-base no mínimo legal, eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a sanção aquém do piso previsto no tipo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não há causas de aumento. No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que a ré faz jus ao benefício, já que é primária (certidão de fls. 261/262), não ostenta maus antecedentes e não constar que se dedicava a outras atividades criminosas. Ausentes motivos idôneos, a redução deve se dar na expressão máxima, o que resulta na pena final de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

À mingua de elementos no que tange à situação econômica da acusada, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Do réu Jean Francisco Lemes

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código penal, verifica-se que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não deve lhe prejudicar, porquanto comum para esse tipo de crime; os antecedentes não lhe prejudicam, porquanto é primário (fls. 259/260); inexistem elementos suficientes

para se definir a personalidade do agente e conduta social; os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias também não devem aumentar a pena-base, já que não apresentam peculiaridades que justifiquem a sua exasperação; as consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime.

Por outro lado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não há, nas circunstâncias judiciais preponderantes, nenhuma peculiaridade a justificar a exasperação da reprimenda.

Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes e, fixada a pena-base no mínimo legal, eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a sanção aquém do piso previsto no tipo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não há causas de aumento. No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, já que é primário (certidão de fls. 259/260), não ostenta maus antecedentes e não constar que se dedicava a outras atividades criminosas. Ausentes motivos idôneos, a redução deve se dar na expressão máxima, o que resulta na pena final de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

À minguia de elementos no que tange à situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a primariedade dos acusados e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Não obstante esta magistrada tenha decidido em outros casos idênticos de maneira diversa, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Nesse sentido, confira-se a novel decisão:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. Ante a necessidade de salvaguardar um dos direitos fundamentais mais preciosos do ser humano, a liberdade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 143.641/SP, rompeu com a resistência registrada nos seus precedentes, quanto à inadmissibilidade do uso do writ constitucional de maneira coletiva. Na oportunidade, assentaram-se diretrizes a respaldar o maior espectro do remédio heroico, entre elas: a existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis; o fortalecimento da abordagem coletiva, em atendimento a maior isonomia às partes em litígio e em prestígio à celeridade processual, mitiga as dificuldades estruturais do acesso das coletividades ao Poder Judiciário. 2. A moldura fática trazida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – mais de mil presos, que, a despeito da reconhecida prática de crime de tráfico privilegiado, cumprem pena de um ano e oito meses, em regime fechado, com respaldo exclusivo no ultrapassado entendimento de que a conduta caracteriza crime assemelhado a hediondo – permite solução coletiva, por reproduzirem a mesma situação fático-jurídica.

Precedente (HC n. 575.495/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020). 3. Há anos são perceptíveis, em um segmento da jurisdição criminal, os reflexos de uma postura judicial que, sob o afirmado escudo da garantia da independência e da liberdade de julgar, reproduz política estatal que se poderia, não sem exagero, qualificar como desumana, desigual, seletiva e preconceituosa. Tal orientação, que se forjou ao longo das últimas décadas, parte da premissa equivocada de que não há outro caminho, para o autor de qualquer das modalidades do crime de tráfico – nomeadamente daquele considerado pelo legislador como de menor gravidade –, que não o seu encarceramento. 4. Segundo a interpretação, consolidada e antiga do Supremo Tribunal Federal (HC n. 111.840, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/12/2013), conforme à Constituição da República, não é considerado hediondo o delito de tráfico de drogas, na modalidade prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 (caracterizada pela quantidade de drogas apreendida não elevada e por ser o agente primário, sem antecedentes penais e sem envolvimento com atividade ou organização criminosa). 5. Em decorrência dessa interpretação, que sobreleva os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, a natureza não hedionda do crime em exame desautoriza prisão preventiva sem a análise concreta dos requisitos do art. 312 do CPP (HC n. 104.339, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 06/12/2012), afasta a proibição, prevista art. 44 da Lei 11.343/2006, de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (HC n. 97.256, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 15/12/2010), e impõe, portanto, tratamento penal com "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (HC n. 118.533, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/9/2016). 6. Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, é clara e reiterada a dicção de enunciados sumulares dos Tribunais Superiores, segundo os quais "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Sum. 718 do STF), "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Sum. 719 do STF) e "É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito" (Sum. 440 do STJ). 7. Esses julgados, por força do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão da norma de abertura positivada no art. 3º do CPP, devem ser observados por juízes e tribunais do país, em nome da segurança jurídica, da estabilidade das decisões do Poder Judiciário, da coerência sistêmica e da igualdade de tratamento dos jurisdicionados, que não podem ficar à mercê de interpretações divergentes, sobre questões de cunho eminentemente jurídico, das que lhes conferiram os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, incumbidos, por comando constitucional, da função de uniformizar a interpretação e a aplicação da Constituição da República e das leis federais (arts. 102, III e 105, III). 8. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 9. Deveras, não condiz com a racionalidade punitiva, ínsita a um Estado Democrático de Direito, que a todo e qualquer autor de tráfico de drogas se imponha o cumprimento de sua pena em estabelecimento penal, em regime fechado, e sem direito a qualquer alternativa punitiva, mesmo se todas as circunstâncias judiciais e legais sejam reconhecidas a seu favor (quantidade pequena de droga, primariedade e bons antecedentes do agente, além de não demonstração de seu envolvimento em atividade ou organização criminosa). 10. E não há de ser esse o proceder de agentes do Estado a quem se confia o exercício da nobre função de dizer o Direito, algo que, no âmbito da jurisdição criminal – que expressa o poder punitivo estatal – reclama dose ainda maior de serenidade e ausência de preconceitos. 11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a

modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis. 12. A documentação, trazida em aditamento à impetração, alude a 1100 homens e mulheres que cumprem pena em regime fechado no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, e sem lhes haver sido autorizada a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos, a despeito de terem sido condenados à sanção mínima do tráfico privilegiado (1 ano e 8 meses de reclusão), ou, quando muito, a uma pena menor que 4 anos de reclusão. A menos que cumpram pena por outro motivo, são pessoas que se encontram indevidamente recolhidas ao precário sistema penitenciário, onerando ainda mais a sociedade, que poderia se beneficiar com serviços comunitários, houvessem as respectivas sanções reclusivas sido convoladas em restritivas de direito. 13. Se a lei é, na visão de julgadores, benevolente com algum tipo de crime, compete ao Congresso Nacional, legitimado pelo voto popular, modificá-la (sempre sujeito, evidentemente, ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal). Não cabe ao Poder Judiciário, o uso de discursos metajurídicos de matiz ideológico ou moral, para incrementar o rigor do sistema punitivo e para contornar, com argumentos aparentemente jurídicos, os limites impostos pela lei penal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os quais, como visto, pela Constituição da República têm a especial competência para interpretar e uniformizar a lei federal e a Constituição em última instância, ante idênticas situações fáticas. 14. Estudo feito pelo Instituto Conectas (relatório disponível no sítio do instituto na web) conclui que “ainda que a decisão do STF no HC 118.533 tenha sido o reconhecimento do tráfico privilegiado como um crime comum, afastando-se a hediondez dos casos em que há aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, com a presente pesquisa verifica-se que juízes de primeira instância, em São Paulo, continuam aplicando tratamento desproporcional ao delito, em comparação com outros delitos sem violência de igual pena.” Alguns julgados – prossegue o relatório – “são expressos em sua afronta à jurisprudência dominante das cortes superiores, tecendo palavras fortes contra

a evolução interpretativa e constituindo, dentro da sua esfera de poder, um espaço blindado contra o tratamento proporcional aos condenados por tráfico de drogas, em qualquer grau.” 15. Pelos dados do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores - Brasília/DF, a Defensoria Pública de São Paulo em 2019, dos 11.181 habeas corpus impetrados no STJ, a ordem foi concedida em 6.869 feitos, 61,43% das impetrações. Mais ainda, aquela Defensoria evidenciou que, no período da pandemia, conforme Levantamento do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, em casos de reconhecido tráfico de menor monta (pouca quantidade de drogas, réus com bons antecedentes e sem provas de anterior atividade ilícita e de integração a organização criminosas), de 64 casos em que Câmaras Criminais do TJSP mantiveram a condenação de acusados por tráfico privilegiado, 53 foram reformadas pelo STJ, ou seja, cerca de 82,80% dos pacientes obtiveram decisão concessiva. 16. Esses dados são a tradução, inequívoca e indesmentível de que o volume de trabalho das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, ocupadas em mais de 50% por habeas corpus oriundos do Tribunal de Justiça de São Paulo (dos 68.778 habeas Corpus distribuídos no STJ em 2019, 35.534 vieram daquele Tribunal), em boa parte se resume a simplesmente reverter decisões que, contrárias às súmulas e à jurisprudência das Cortes Superiores, continuam a grassar, crescentemente, em algumas das 16 Câmaras Criminas daquele Tribunal. 17. Essa insistente desconsideração de alguns órgãos judicantes às diretrizes normativas derivadas das Cortes de Vértice produz um desgaste permanente da função jurisdicional, com anulação e/ou repetição de atos, e implica inevitável lesão financeira ao erário,

bem como gera insegurança jurídica e clara ausência de isonomia na aplicação da lei aos jurisdicionados. 18. Em suma, diante da mesma situação factual – tráfico de pequena monta, agente primário, sem antecedentes penais, sem prova de vínculo com organização criminosa e de exercício de atividade criminosa (que não seja, é claro, a específica mercancia ilícita eventual que lhe rendeu a condenação) –, há de reconhecer-se que: 18.1. A Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), em seu art. 112, § 5º (com a redação que lhe conferiu a Lei n. 13.964/2019) é expressa em dizer que “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”; 18.2. O Ministério Público, a par da função exclusiva de exercitar a ação penal pública, é também constitucionalmente incumbido da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da C.R.), e deve agir de acordo com critérios de objetividade, compromissado, pois, com o direito (custos iuris) e com a verdade (obbligo di verità, na dicção de LUIGI P. COMOGLIO e VLADIMIRO ZAGREBELSKY, Modelo accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano: Giuffrè, ano 36, fasc. 2 – aprile-giugno/1993, p. 484). Logo, a acusação formulada pelo Ministério Público há de consubstanciar uma imputação responsavelmente derivada da realidade fático-jurídica evidenciada pelo simples exame do inquérito policial, muitas vezes já indicativa de que não se cuida de hipótese de subsunção da conduta do agente ao crime de tráfico de drogas positivado no caput do art. 33 da LAD. 18.3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores – quer por meio de Súmulas (verbetes n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ), quer por meio de julgamentos proferidos pela composição Plena do Supremo Tribunal Federal, seguidos por inúmeros outros julgamentos da mesma Corte e do STJ – é uníssona e consolidada no sentido de que: 18.3.1. Não se pode impor regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito e sem a idônea motivação, que não pode decorrer da mera opinião do julgador; 18.3.2. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador; 18.3.3. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e nas ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 18.3.4. O autor do crime previsto no art. 33, § 4º da LAD não pode permanecer preso preventivamente, após a sentença (ou mesmo antes, se a segregação cautelar não estiver apoiada em quadro diverso), porque: a) O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal – e copiosa jurisprudência das Cortes Superiores – afastou a vedação à liberdade provisória referida no art. 44 da LAD; b) Não é cabível prisão preventiva por crime punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos (art. 313, I do Código de Processo Penal; c) O tempo que o condenado eventualmente tenha permanecido preso deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º do CPP), o que, a depender do tempo da custódia e do quantum da pena arbitrada, implicará imediata soltura do sentenciado, mesmo se fixado o regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto (dado que, como visto, não se mostra possível a inflicção de regime fechado ao autor de tráfico privilegiado). 19. Essas são, portanto, as diretrizes que devem ser observadas – e normalmente o são, pela maioria de juízes e tribunais de todo o país –, por decorrerem de precedentes qualificados das Cortes Superiores (súmulas de jurisprudência, julgamentos pelo Tribunal Pleno do STF, recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos do STJ, e extraordinários em repercussão geral, pelo STF), sobre questões jurídicas assentadas a partir da mesma situação fática, sempre ressalvada, naturalmente, a eventual indicação de peculiaridades do caso examinado, a permitir, mediante idônea e responsável motivação, distinguir a hipótese em julgamento da que fora decidida nos referidos precedentes. 20. Na espécie, a gravidade excepcional do delito não se sustenta, visto que o crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva

em apreço e, embora apreendidas cocaína e crack, a quantidade da droga, ao contrário do afirmado, não foi relevante (5,6 g no total). 21. Habeas Corpus concedido, para: 21.1. Em relação ao paciente individualizado na impetração, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena. 21.2. Em relação aos presos que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto. 21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão – salvo os casos do item anterior – determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de progressão ao regime aberto em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 21.4. Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. Determinação para que se dê cumprimento desta ordem de Habeas Corpus, inclusive para que se providencie, junto aos respectivos juízos, a imediata expedição de alvarás de soltura aos presos que, beneficiados pelas medidas ora determinadas, não estejam presos por outros motivos.” (grifo nosso).

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaindo, preferencialmente, em favor daquelas voltadas à reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: “A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição”. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011”. HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

DECIDO.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR JEAN FRANCISCO LEMES, qualificado à fl. 04, e ALESSANDRA APARECIDA DE TOLEDO, qualificada à fl. 05, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. art. 29, do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no patamar unitário mínimo.

Faculto aos réus o direito de apelar em liberdade.

Substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo em favor de entidades assistenciais, recaindo, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Se ainda não determinado, desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará

reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Fica decretada, igualmente, na forma do art. 243, da Constituição Federal combinado com artigo 63, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006, a perda do veículo apreendido às fls. 14, qual seja, o FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, placa EGL0240, chassi 9BD17309T94240594, ano/modelo 2008/2009, pois utilizado para a atividade de traficância, devendo aquela que consta como proprietária perante o Detran, qual seja, Cleusa Lanzilotti Lemes, ser cientificada do teor desta decisão. A propósito, em 17 de maio de 2017, ao tratar da questão do confisco de bens utilizados para o narcotráfico no julgamento do Recurso Extraordinário 638491/PR, de relatoria do ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese de repercussão geral: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal".

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 98, §3º do CPC, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal.

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

P.I.C.

São Luiz do Paraitinga, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA